

1507392-77.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... em operação de repressão ao tráfico, estivessem trajados de garis.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos
18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507392-77.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507392-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL ALVES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de RAFAEL ALVES PEREIRA, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Narra-se na denúncia: “no dia 25 de março de 2021, por volta das 04h00, na Rua Manuel Francisco Araújo, nº 113, Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca da Capital, RAFAEL ALVES PEREIRA, qualificado a fls. 6, em ocasião de calamidade pública durante a pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo 06/2020), trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 70 (setenta) porções de Cannabis Sativa L. contendo a substância entorpecente tetrahidrocannabinol (THC) vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 143,6g (cento e quarenta e três gramas e seis decigramas); 3 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 0,5g (cinco decigramas); e 50 (cinquenta) frascos de lança-perfume, contendo a

substância Tricloroetileno (TCE), com peso líquido de 275ml (duzentos e setenta e cinco mililitros), entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante às fls. 1, boletim de ocorrência às fls. 2/4, auto de exibição e apreensão às fls. 5 e laudo de constatação às fls. 16/19.”.

Promovida a notificação, foi apresentada defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial de constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo, que apontam se tratar de drogas descritas nas listas F1 e F2 da Portaria n. 344/1998-SVS/MS (complemento das normas penais em branco constantes da Lei n. 11.343/06, por força do art. 66 do referido diploma legal), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Rogerio relatou que se recorda do caso; que nesse dia estava havendo uma operação chamada Lockdown e tinham um monte de mandado para cumprir e alguns lugares para ir; que esse lugar já foi mapeado e é ponto de tráfico há muitos anos; que ele foi surpreendido quando chegaram; que ele estava com uma sacola com entorpecentes; que ele tinha cocaína, maconha, crack, lança-perfume; que esse local da abordagem é ponto de drogas muito antigo; que já tinha trabalhado nessa área de 2007 a 2012 e nessa época já existia, desde quando chegou, em 2007; que são quatro quadras, tem as escadas, e conseguem correr, mas aí ele foi surpreendido; que a operação era de repressão ao tráfico de drogas; que apreenderam dois aparelhos; que ele chegou a falar que estava vendendo mesmo; que não chegou a perguntar há quanto tempo ele estava vendendo; que não conhecia o réu antes da ocorrência; que o réu não chegou a correr, pois é um local em que ou chegam muito perto e seguram, ou ele começa a correr; que vieram de um ponto cego e conseguiram chegar perto dele apesar dos olheiros; que acha que ele não precisou nem correr, pois foi surpreendido; que não havia outras pessoas nesse local, não lembra se ele estava sozinho; que nesse horário geralmente fica o vapor e os olheiros na ponta da linha; que por isso ele tem dois aparelhos, um da empresa do crime e outro

particular; que nesse dia provavelmente vieram por cima, passaram pelos olheiros, os maiores alvos dessa operação; que não se lembra se havia alguém com ele; que ele não tinha dinheiro; que não teve campana, é um local em que não há condição de fazer campana, ou surpreende ou não pega ninguém; que isso foi de madrugada.

A testemunha Rafael relatou que a operação foi bem intensa, fizeram várias prisões, e nesse caso específico, localizaram o rapaz em um ponto de tráfico já conhecido e ele trazia consigo maconha, crack ou cocaína, e lança-perfume; que ele não esboçou reação; que ele cooperou com a equipe, disse que estava lá mesmo, passava por dificuldades, e por isso optou pela venda; que juntamente com outras ocorrências foi elaborado no decorrer do dia; que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, há biqueiras uma na frente da outra; que não conhecia o réu por nome, talvez tenha passado por ele porque toda vez passam nesse local para tentar coibir o tráfico; que a abordagem foi de madrugada; que não se recorda se foi localizado dinheiro; que ele cooperou; que acha que não houve tempo de ele dispensar a sacola, pois chegaram de um modo furtivo; que era uma sacola de plástico, não se recorda da cor, mas estava na mão dele

O acusado relatou que não estava traficando, era aniversário de sua filha, ia comprar coisa para ela; que foi o primeiro dia em que foi preso; que não mexe com nada disso, era umas dez horas da noite; que estava indo comprar umas pingas; que era aniversário de sua filha de quatro anos; que não viu a sacola, só foi algemado; que não conhecia esses policiais; que eles não estavam com farda, e sim com roupa de gari; que havia tomado umas pingas, mas hoje não tomou.

Diante das provas produzidas, quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

No caso ora em apreço, verifica-se que o depoimento dos policiais é uníssono quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão. Quanto à hipótese alternativa ventilada, mostra-se de reduzida verossimilhança, tendo em vista que os policiais não conheciam o acusado, o horário da abordagem (madrugada) não era compatível com a versão de que o acusado estaria indo comprar pinga em razão do aniversário de sua filha de quatro anos, e tampouco é verossímil que os policiais, em operação de

repressão ao tráfico, estivessem trajados de garis.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito), o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a folha de antecedentes juntada aos autos não contém nenhuma condenação penal definitiva apta a ser desvalorada nesta fase (cf. Súmula 444/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria, para fixação do patamar da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fim de evitar bis in idem indireto, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM, Plenário, j. 3.4.2014, Tema 712 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887511/SP, Terceira Seção, j. 09/06/2021).

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes, razão pela qual a pena provisória deve ser mantida no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, configuradora do assim denominado "tráfico privilegiado", a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa. No caso, todos esses requisitos estão preenchidos.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame. Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais de uma espécie de substância ilícita, de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Ademais, quanto à cocaína, trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga apreendida, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita.

Assim, fixa-se a fração de diminuição no patamar intermediário de 1/2 (um meio), a resultar na pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto, com base no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que eventual prisão preventiva não interfere na fixação do regime inicial, pois a pena originária já foi fixada no regime menos gravoso (aberto).

Ante o preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, as quais ficam desde já individualizadas como (1) prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária que será informada posteriormente, em audiência admonitória, para destinação a entidade pública ou privada com destinação social, em atenção à Resolução n. 154/12-CNJ; e (2) prestação de serviços à comunidade, por tempo igual ao da condenação, em entidade a ser designada na fase de execução penal.

Ante a substituição por pena restritiva de direitos, fica prejudicado o exame da suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III).

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado RAFAEL ALVES PEREIRA ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos na forma supra, mais 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, razão pela qual é cabível a manutenção do acusado em liberdade até o trânsito em julgado (CPP, art. 387, § 1º).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, prossiga-se na forma dos arts. 479 e 480 das NSCGJ.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

São Paulo, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA